

1500370-16.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... o Réu deve ser condenado pelo tráfico de drogas e absolvido pelo art. 16 do Estatuto do Desarmamento; há prova da autoria e da materialidade quanto ao tráfico; a pena-base deve ficar acima do mínimo legal; o Réu tem outras passagens; a confissão não deve ser utilizada; não há que se falar no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; o regime inicial deve ser o fechado.

Já a defesa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE Cachoeira Paulista

2ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, S/N, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1347,

Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1500370-16.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1500370-16.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VALDIR DOS SANTOS INÁCIO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia em face de VALDIR DOS SANTOS INÁCIO pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

De acordo com a denúncia:

"(...) no dia 23 de abril de 2.022, por volta das 17h, na Rua Isaac da Silva Cunha, n.º 68, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, VALDIR DOS SANTOS INÁCIO, vulgo "Dinho", qualificado à fl.07, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio a terceiros, 41,67g (quarenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína, divididas em 62 "pinos"; 5g (cinco gramas) de cocaína na forma de crack, divididas em 40 (quarenta) "pedras"; e 7,27g (sete gramas e vinte e sete centigramas) da Cannabis sativa L," vulgarmente conhecida por maconha, em uma "trouxa", substâncias estas entorpecentes que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar (fls.33/35).

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, VALDIR DOS SANTOS INÁCIO, vulgo "Dinho", qualificado à fl.07, recebeu, possuía e tinha em depósito acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (conforme laudo pericial a ser oportunamente encaminhado ao Juízo).

Segundo o apurado, policiais militares receberam reiteradas informações no sentido de que VALDIR, pessoa conhecida dos meios policiais em razão da prática do tráfico de substâncias entorpecentes, estaria andando armado e efetuando disparos de arma de fogo no quintal de sua residência, na companhia de outros indivíduos.

No local, os policiais divisaram VALDIR. Indagado a respeito dos fatos, VALDIR confessou que havia recebido de seu amigo Thales uma certa quantidade de munições e, quando percebeu a aproximação da viatura policial, arremessou tais as munições no quintal.

Franqueada a entrada aos policiais no imóvel eles localizaram uma sacola plástica contendo 150 (cento e cinquenta) munições calibre 5.56, 50 (cinquenta) munições calibre 7.62 e 73 munições de festim, calibre 5.56.

Na sequência, VALDIR confessou aos policiais que armazenava entorpecentes e apetrechos para manipulá-los.

De efeito, atrás de um sofá localizaram uma caixa de papelão no interior do qual estavam as porções de cocaína e cocaína na forma de crack, conforme supramencionado. Além disso, os policiais localizaram 1.900 (mil e novecentos) eppendorf's, 47 (quarenta e sete) sacolés e 11 (onze) potes de fermentos vazios. Ainda, na cozinha localizaram um liquidificador, uma travessa de vidro marrom e dois copos de liquidificador contendo resquícios de cocaína.

Por fim, na posse de VALDIR foi apreendida uma "trouxa" contendo maconha e um aparelho de telefone celular.

Diante das circunstâncias da apreensão, da notícia anterior, da quantidade de entorpecentes, conclui-se que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio a terceiros".

Às fls. 184/189, o Réu apresentou resposta à acusação.

Às fls. 216, houve o recebimento da denúncia.

Às fls. 219, foi negada a absolvição sumária e designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em 21/07/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente; o Réu deve ser condenado pelo tráfico de drogas e absolvido pelo art. 16 do Estatuto do Desarmamento; há prova da autoria e da materialidade quanto ao tráfico; a pena-base deve ficar acima do mínimo legal; o Réu tem outras passagens; a confissão não deve ser utilizada; não há que se falar no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; o regime inicial deve ser o fechado.

Já a defesa, em alegações finais, defendeu que: o Réu deve ser absolvido quanto ao crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento; não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; os relatos policiais são insuficientes à condenação; deve haver a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; caso contrário, é de se aplicar o art. 33, §4º, da Lei de Drogas; é possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003

No caso concreto, não há prova suficiente para a condenação.

Em suas alegações finais, o MP requereu a absolvição por ausência de provas.

Como se sabe, a condenação criminal exige um grau muito elevado de probabilidade quanto às alegações de fato, a ponto de haver o dever de absolver quando não há provas ou quando existe uma dúvida razoável em favor do acusado:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

- I - estar provada a inexistência do fato;
- II - não haver prova da existência do fato;
- III - não constituir o fato infração penal;

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII - não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II - ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

III - aplicará medida de segurança, se cabível. (grifos acrescidos)

No caso concreto, as provas não sustentam a acusação suficientemente, já que, apesar de haver convergência quanto aos desvios feitos por THALES, não ficou clara a participação do Réu no desvio ou na guarda das munições.

Desta forma, o Réu deve ser absolvido com base no art. 386, VII, do CPP.

II.2 Do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 31/33 demonstra que foram apreendidas na posse do Réu: a) 47 sacolés; b) 1900 microtubos vazios; c) 11 frascos vazios de fermento; d) 1 liquidificador; e) 2 copos de liquidificador; f) R\$34,00; g) 62 eppendorfs com cocaína; h) 40 pedras de crack; i) 2 porções de maconha.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 39/41, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 137/139 constatou que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se do total de: a) 41,67g de massa líquida de cocaína; b) 40 pedras de crack (5g de massa líquida); c) 7,27g de massa líquida de maconha.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado VALDIR DOS SANTOS INÁCIO foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha VINÍCIUS UCHOA DA SILVA SANTOS afirmou que: o COPOM irradiou uma ocorrência que DINHO, um traficante do bairro, estava disparando armas de fogo no quintal da sua residência e ensinando pessoas a atirar; a ocorrência em específico já indicava o DINHO como autor dos disparos; foram ao local (já sabiam o local em que o Réu morava, por denúncias de tráfico de drogas no bairro); na casa do Réu, viram o Réu no fundo do quintal; já imaginou que ele

estaria dispensando algum objeto; o Réu recebeu os policiais e ouviu as denúncias; o Réu confessou que havia recebido as munições de THALES e que havia jogado no quintal quando viu os policiais; deixou os policiais entrarem na residência; o Réu mostrou o local em que estavam as munições de fuzil; perguntaram se havia drogas na residência e ele confessou; saíram 5 pessoas da residência (uma delas era THALES, militar do Exército); THALES confirmou que havia subtraído as munições do Exército e deixado com o Réu; encontraram crack, maconha e cocaína na casa; foram encontradas substâncias para refino da droga; também encontraram pinos e sacolés; também acharam petrechos e resquícios de cocaína; foram todos conduzidos até a delegacia de Lorena; durante a ocorrência, chegaram informações que um indivíduo chamado JOW se evadiu com as armas que estavam sendo usadas na casa de DINHO, mas ele não foi localizado; já conhecia o DINHO pelas ocorrências de tráfico de drogas no local; perguntaram se havia drogas na casa e o Réu apontou o local, narrando o que ele fazia para refinar a droga e realizar o tráfico; a droga estava atrás do sofá; a informação era de que ele morava sozinho no local; solicitaram apoio de outras viaturas para o local; acha que até a força tática foi lá para encontrar JOW (que fugiu com as armas); as armas de fogo não foram encontradas; THALES falou que subtraiu as munições do Exército e entregava para DINHO guardar.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha JOSÉ PAULO DA SILVA afirmou que: receberam uma ocorrência de disparo de arma de fogo no endereço; a denúncia falava que GORDO / DINHO (traficante no bairro) estaria fazendo disparos de armas de fogo no quintal e estaria ensinando outras pessoas a atirar; foram até o local; entrou numa residência ao lado para tentar ver alguma coisa no fundo do quintal, mas não conseguiu ver; quando retornou, o sargento já tinha feito contato com o Réu e já havia entrado no local; o sargento viu o Réu dispensando algo no fundo; o sargento voltou com uma sacola com as munições de fuzil; havia outros indivíduos no local; o Réu falou que havia drogas na residência; no local, foram encontrados cocaína e crack, além de pinos para acondicionar cocaína; também localizaram utensílios domésticos com resquícios de cocaína; o Réu explicou que fazia misturas para preparar a droga para uso pessoal e dos amigos; quanto às munições, afirmou que estava guardando as munições de THALES, que era militar do exército; os outros indivíduos foram liberados; não tinha abordado o Réu antes; não encontraram JOW no local; quando estavam na delegacia, falaram que JOW estaria na casa e saiu pelos fundos; dizem que JOW fugiu com as armas de lá; não fizeram outras diligências atrás dessas armas.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha JOÃO ANTÔNIO PEDROSO DA SILVA afirmou que: é vizinho do Réu; no dia dos fatos, estava de folga e viu os fatos acontecerem; viu os policiais chegarem e a movimentação na rua; nunca viu o Réu mexendo com drogas nem com armas de fogo; era vizinho de muro do Réu; não escutou disparos de arma de fogo; no dia, ouviu barulho, mas achou que eram "bombinhas"; eram vários estouros; um policial pediu para entrar na residência da testemunha porque estaria havendo vários tiros no local; achou que eram estouros de bombinhas.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha ANTÔNIO ROCHA afirmou que: o Réu trabalhou para a testemunha; era uma boa pessoa e trabalhador; o Réu era pedreiro; nunca teve problemas com o Réu com drogas; nunca presenciou o Réu com armas de fogo; o Réu é muito brincalhão; nunca viu o Réu com arma de fogo.

Em seu interrogatório, o Réu VALDIR DOS SANTOS INÁCIO afirmou que: não foi dessa forma; quanto às munições, THALES tinha levado no dia para verem e estourarem as munições de festim; queriam estourar as munições de festim para ver; os potes de fermento eram para cozinhar; é usuário de maconha; guardava o restante em troca de drogas; guardava as drogas e os pinos em troca de drogas; não estava guardando as munições; THALES falou que desviava as munições; THALES levou só para eles verem; colocaram as munições no fogo para ouvir os barulhos; estavam colocando na panela de pressão; não pratica tráfico de drogas; nunca foi abordado por policiais; as drogas estavam no quintal.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio

idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato.

(TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos foram coerentes entre si, convergindo quanto ao fato de que as drogas foram encontradas na residência do Réu, que as guardava.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena,

afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

Ao contrário do argumentado pela defesa técnica, não é viável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

O TJSP tem precedentes no sentido de que não deve haver a desclassificação quando as circunstâncias da conduta indicarem que o agente, surpreendido em posse de drogas, não o fazia para uso próprio:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500579-91.2021.8.26.0597; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Parcial razão. Materialidade e autoria indúvidas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 4,72g (quatro gramas e setenta e dois centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, com peso bruto de 500,06g (quinhentos gramas e seis centigramas). Prova oral robusta. Inviabilidade de desclassificação para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendida não ultrapassa a normalidade à espécie, devendo manter-se o aumento da basilar apenas com relação aos maus antecedentes, na fração de 1/6 (um

sexto). Comprovada reincidência. Impossível a concessão do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500181-14.2021.8.26.0123; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da defesa - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante - Suposto usuário de drogas admitiu na fase inquérito que o acusado lhe vendeu parte da droga apreendida - Desclassificação para o artigo 28 da Lei Drogas - Impossibilidade - Contexto fático não sugere que a droga seria para o consumo do acusado, mesmo porque 4 porções de cocaína foram apreendidas na posse de terceiro, após o acusado tê-las vendido - Presentes os requisitos do "privilégio" (§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas), deve a diminuição de pena ser feita na fração máxima (2/3) - Inviabilidade de se operar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como modificar o regime semiaberto, porquanto, no curso desta ação penal, o acusado foi condenado outras duas vezes pelo mesmo crime - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1501281-78.2020.8.26.0530; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

No caso concreto, a confissão do Réu e a grande quantidade de drogas, de pinos vazios e outros petrechos indicam que a conduta do agente não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas, de sorte que é inviável a desclossificação pretendida.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu VALDIR DOS SANTOS INÁCIO, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciariade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu VALDIR DOS SANTOS INÁCIO pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei

11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado com maus antecedentes, como se vê às fls. 47/55 (execução criminal n. 7000003-40.2008.8.26.0102), razão pela qual a circunstância pode ser valorada negativamente a; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: tendo em vista a natureza da droga (crack), com alto poder viciante, e considerando que a figura do art. 33, §4º, caput, será afastada diante dos maus antecedentes, é possível aumentar a pena base por conta da natureza da droga, com base na nocividade do crack.

Por isso, reconheço duas circunstâncias negativas aplico o aumento de 1/4 sobre o intervalo da pena abstrata e fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias multa.

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da confissão, o que permite a redução em 1/6.

Por isso, a pena intermediária é fixada em 6 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa.

Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

Em sede de julgamentos de recursos especiais repetitivos (Tema 1139), o STJ fixou tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Desta forma, só é possível afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas se: a) houver maus antecedentes, inclusive por fato anterior à presente imputação, mas com trânsito em julgado posterior ao presente processo; b) houver reincidência; ou c) as circunstâncias do caso concreto (não outros processos) indicarem que não se trata de uma conduta pontual ou iniciante e que há efetiva dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa. No caso concreto, nota-se que o agente tem maus antecedentes (execução penal de n. 7000003-40.2008.8.26.0102, conforme certidão de fls. 47/55)., razão pela qual não é possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Por isso, não aplico a causa de diminuição de pena e fixo a pena definitiva em 6 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois não há dados sobre a situação econômica do réu.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I) e a suspensão condicional da pena (art. 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

A) ABSOLVER o réu VALDIR DOS SANTOS INÁCIO quanto à imputação da prática do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com base no art. 386, VII, do CPP.

B) CONDENAR o Réu VALDIR DOS SANTOS INÁCIO pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 6 anos e 03 meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 625 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. EXPEÇAM-SE guias de execução provisória. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos e dos bens nas fls. 31/33 (exceto do celular). Some-se a isso o fato de que O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

Com relação ao celular apreendido (objeto do incidente de n. 0000764-

05.2022.8.26.0102), remeta-se o bem à Justiça Militar da União.

Em atenção à certidão de fls. 160/171, solicitem-se informações ao 5º Batalhão de Infantaria Leve, na cidade de Lorena/SP, sobre o local para o qual o celular deve ser encaminhado.

Insira-se cópia da presente sentença no incidente (0000764-05.2002.8.26.0102).

Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia e do bem em favor do FUNAD.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresse acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e

lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cachoeira Paulista, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA